

1500506-71.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... mas negou estar trabalhando para o tráfico. Afirmou que tem passagens por tráfico, roubo e furto. Falou que reside na Rua Manoel Bandeira, que termina na travessa em que foi abordado, e que estava indo para casa. Falou que não avisou ninguém e que não conhece Rafael (que estava vendendo drogas). Negou ter envolvimento com o tráfico. Disse que foi abordado junto com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, . - Vila Conceição

CEP: 09912-010 - Diadema - SP

Telefone: (11) 4056-6600 - E-mail: diadema3cr@tjsp.jus.br

1500506-71.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500506-71.2022.8.26.0537 Controle nº 397/2022

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL SILVA SOUZA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

RAFAEL SILVA SOUZA e JOILSON COSTA LAURIANO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 10 de março de 2022, por volta das 14:40 horas, na Travessa Gonçalves Dias, altura do n.º 65, Bairro Jardim Campanário, previamente ajustados e com identidade de propósitos entre si, adquiriram, traziam consigo e guardavam, para consumo de terceiros, maconha, cocaína e "crack", drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Foi concedida liberdade provisória ao acusado Rafael, por decisão do Juiz de Plantão, mediante a imposição de medidas cautelares e o recolhimento de fiança, arbitrada em R\$ 4.040,00 (fls. 92/97). O acusado Rafael foi posto em liberdade em 11.03.22 (fls. 135). O Defensor Público requereu a dispensa do pagamento da fiança pelo acusado (fls. 109/111), tendo o M.P opinado favoravelmente (fls. 131). Foi afastamento o recolhimento da fiança, mantendo-se as demais cautelares fixadas pelo Juízo de plantão, por decisão de 11.04.22 (fls. 136).

A prisão em flagrante do réu Joilson foi convertida em prisão em flagrante por decisão do Juiz de Plantão (fls. 92/97). A prisão preventiva foi reapreciada, e mantida, por decisão de 12.07.22 (fls. 154). O Defensor Público requereu a revogação da prisão preventiva do acusado (fls. 161/164), tendo o M.P se manifestado contrariamente (fls. 169/170). A revogação da prisão preventiva foi indeferida por decisão de 04.10.22 (fls. 174).

Foi apresentada defesa prévia (fls. 161/162), sendo recebida a denúncia em 04.10.22 (fls. 173). O réu Joilson foi interrogado no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF de que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais. Quanto ao corréu Rafael foi decretada a sua revelia, posto que não compareceu, nem comprovou o impedimento para fazê-lo.

A Dra. Promotora de Justiça, nos debates orais, requereu a condenação dos acusados, por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com aumento da pena pela quantidade de drogas; a aplicação da redução do art. 33 e regime aberto para o réu Rafael, por ser primário e sem antecedentes; quanto ao acusado Joilson, que possui antecedentes e dupla reincidência, requereu seja afastada a redução do art. 33, § 4.º e fixado regime fechado, além do perdimento do dinheiro apreendido.

O Defensor Público requereu a absolvição dos acusados por insuficiência de provas. Em caso de eventual condenação, requereu em relação ao réu Rafael requereu seja considerada a atenuante da confissão, redução do art. 33, § 4.º no máximo, fixação de regime aberto, com as substituições legais, por ser primário, e direito de recorrer em liberdade. Quanto ao réu Joilson requereu que ocorra a desclassificação para o crime do art. 37 ou em caso de eventual condenação a fixação de regime semiaberto.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Aplico a "emendatio libelli" quanto ao réu Joilson para constar que a qualificação legal correta é do art. 37 da Lei n.º 11.343/06, uma vez que conforme descrito na denúncia, este atuava apenas como "olheiro", não tendo qualquer responsabilidade sobre a droga apreendida com o acusado Rafael.

O acusado Rafael confessou a prática do crime na fase policial (fls. 04). Disse que trabalhava como gerente na "Pizzaria Rap10", diariamente das 16:00 às 00:00 horas, e recebia R\$ 1.600,00 por mês. Afirmou que naquele mês estava "apertado" (sic) e aceitou a proposta de um desconhecido para vender drogas. Declarou que era seu primeiro dia no tráfico. Relatou que chegou na "biqueira" por volta das 13:00 horas e que ficaria naquela até as 16:00 horas, pelo que receberia R\$ 500,00, porém foi abordado antes do final do turno. Narrou que quando chegou na "biqueira" um homem desconhecido compareceu no local a pé e entregou uma sacola plástica contendo maconha, cocaína e "crack", informou os valores das drogas e que passaria ali no decorrer do dia para recolher o dinheiro das vendas, depois foi embora. Falou que vendia a porção de maconha por R\$ 20,00, o invólucro de cocaína por R\$ 5,00 ou R\$ 10,00, a depender do tamanho do invólucro, e a pedra de "crack" por R\$ 5,00.

Informou que possuía uma "passagem", mas foi absolvido. Afirmou que estava traficando as drogas quando foi abordado e levado à delegacia.

Em juízo, não foi interrogado, posto que não compareceu, sendo decretada a sua revelia.

O réu Joilson negou a prática do crime na fase policial (fls. 18). Declarou que é usuário de "crack" e que não possuía trabalho formal, mas negou estar trabalhando para o tráfico. Afirmou que tem passagens por tráfico, roubo e furto. Falou que reside na Rua Manoel Bandeira, que termina na travessa em que foi abordado, e que estava indo para casa. Falou que não avisou ninguém e que não conhece Rafael (que estava vendendo drogas). Negou ter envolvimento com o tráfico. Disse que foi abordado junto com Rafael e conduzido ao distrito policial.

Em juízo, narrou que mora nas proximidades, viu os policiais chegando por trás, agrediram o réu Rafael e foi para separar, achando que era um briga. A sua irmã foi pegar o seu R.G e entregou para os policiais. O local é ponto de tráfico, já teve passagem, mas não estava envolvido neste crime. Em frente da sua casa é o ponto de tráfico. Tem condenações pelos crimes dos arts. 157 e 33 e estava em Livramento Condicional. Trabalhava como ajudante de pedreiro. Conhecia o corréu de vista. Não

gritou para avisar a polícia.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 02/03), disseram que durante operação de combate ao tráfico, diligenciaram em uma viatura descaracterizada até o local dos fatos, um escadão próximo à Travessa Gonçalves Dias, conhecido ponto de tráfico. Relataram que se dividiram, de forma que o policial Adriano seguiu por uma ponta do escadão e o policial William seguiu na travessa pela outra extremidade, visando cercar o "vapor" (responsável pela venda de drogas). Narraram que quando o policial Adriano adentrou à travessa, o réu Joilson, que estava próximo do policial William, gritou tentando avisar o "vapor" (réu Rafael) sobre a aproximação policial, mas foi imediatamente abordado por William, enquanto o réu Rafael foi abordado pelo policial Adriano. Narraram que em busca pessoal ao réu Joilson não localizaram nada de ilícito e que, de início, ele não soube dizer o que fazia no local, mas depois confessou que estava trabalhando de "Capa" ("olheiro"). Afirmaram que em revista pessoal localizaram na posse do réu Rafael a quantia de R\$ 50,00, e na sacola plástica que ele trazia consigo vários invólucros de substâncias entorpecentes (maconha, cocaína e "crack"). Falaram que o réu Rafael confessou estar traficando as drogas e disse que era seu primeiro dia no tráfico.

Adriano (policial), em juízo, afirmou que o local é conhecido como ponto de tráfico, viram duas pessoas paradas no "escadão", ele foi de um lado e o policial William de outro. Narrou que o réu Rafael estava com a sacola e o outro gritou "molhou". O réu Rafael tentou fugir, mas se deparou com ele, que o abordou. Na sacola que estava com o réu Rafael havia drogas (divididas em porções) e dinheiro e réu Joilson o avisava. Os dois reus confessaram. Não conhecia os réus anteriormente. Narrou que não se recorda se Joilson alegou que morava perto, porque foi abordado por outro policial.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial William. Abordou o réu Joilson, o qual gritou polícia. O réu Joilson falou que era "olheiro" e Rafael que era "vapor". Foram apreendidas drogas, divididas em porções, e dinheiro com o réu Rafael.

O fato de a testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA - Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º 1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24). A quantidade (fls. 49 - 50 porções de maconha, 43 invólucros de cocaína e 59 pedras de "crack") e a diversidade (maconha, cocaína e "crack") de drogas apreendidas, que estavam divididas em invólucros, a apreensão de dinheiro, cuja procedência o acusado não comprovou, a confissão do réu Rafael, bem como os depoimentos dos policiais demonstram o tráfico, pois não teriam como adquirir essa quantidade se não fosse traficante.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

A confissão extrajudicial do réu Rafael foi corroborada pelos depoimentos dos policiais, bem como pela apreensão de drogas e dinheiro em seu poder.

*****A negativa do acusado Joilson está isolada nos autos, além disso, é reincidente específico (fls. 64), o que retira a credibilidade de sua versão. Irrelevante que não tenham sido presenciados atos de mercancia, posto que denunciados pelas condutas de adquirir, trazer consigo e guardar.

A materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 53/55) e laudo definitivo (fls. 119/121).

Assim, impõe-se a condenação dos acusados que segundo consta dos autos, o réu Joilson possui antecedentes (fls. 64 – proc. 24588-35.2007 – pena julgada extinta pelo cumprimento em 11.07.12 – fls. 199; fls. 64/65 – proc. 26875-05.2006 – pena julgada extinta pelo cumprimento em 11.07.12 – fls. 199; fls. 65 – proc. 35484-19.2012 – pena julgada extinta por indulto em 29.07.16 – fls. 199) e é reincidente (fls. 63 – proc. 67770-98.2016) e o corréu Rafael é primário (fls. 218/221).

O art. 5.º inc. XLVI da Constituição Federal prevê que “a lei regulará a individualização da pena” e o art. 61, inc. I, do Código Penal determina que a reincidência é circunstância agravante da pena.

Conforme R.E. 723.211, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 25.06.13:

“O Plenário desta Corte, no julgamento do RE453.000/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, no dia 4/4/2013, em regime de repercussão geral, julgou o mérito do tema 114 e negou provimento ao RE que alegava a inconstitucionalidade do agravamento da pena em virtude da reincidência, consolidando o entendimento de que não configura bis in idem.

Desse modo declarou ser constitucional a aplicação do instituto da reincidência como agravante da pena em processos criminais (art. 61, I, do Código Penal)”.
Assim, a reincidência do acusado Joilson será considerada como circunstância agravante.

Passo a individualizar a pena a ser aplicada aos acusados.

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, especialmente que tem antecedentes criminais, fixo a pena-base para o acusado Joilson em 2 anos e 4 meses de reclusão e 350 dias-multa, à razão mínima por inexistirem elementos quanto à real situação econômica do acusado. Aumento a pena de 1/6 em razão da reincidência.

Inaplicável a redução do art. 33, § 4.º, uma vez que esta incide apenas em relação ao tráfico previsto no art. 33.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, pois conforme prevê o art. 33, § 2.º, “b” e “c” só se aplicam regimes mais brandos ao “condenado não reincidente”. As circunstâncias não são favoráveis, pois possui antecedentes por furto (fls. 64 – proc. 24588-35.2007 – pena julgada extinta pelo cumprimento em 11.07.12 – fls. 199), receptação (fls. 64/65 – proc. 26875-05.2006 – pena julgada extinta pelo cumprimento em 11.07.12 – fls. 199) e roubo (fls. 65 – proc. 35484-19.2012 – pena julgada extinta por indulto em 29.07.16 – fls. 199), além de ser reincidente por tráfico (fls. 63 – proc. 67770-98.2016), o que denota personalidade voltada para a prática de crimes, os quais são seu meio de vida, uma vez que sequer provou possuir ocupação lícita e estava em livramento condicional quando praticou o crime (fls. 64), o que demonstra que não teria responsabilidade para cumprir regime menos rigoroso; de forma que não preenche os requisitos da Súmula 269 do STJ (“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”).

Inaplicável o disposto no art. 387, § 2.º, do CPP, diante de sua inconstitucionalidade por violar os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da igualdade, já que a fixação da pena e regime estão previstos nos arts. 33 e 68, ambos do Código Penal (norma de direito material), sendo que a progressão de regime deve ser apreciada pelo juiz da execução de acordo com o art. 112 da LEP que é lei especial e prevalece sobre a geral, ou seja, “Lex specialis derogat generali” (Lei especial derroga a geral), não se justificando que o preso provisório possa obter tal benefício sem preencher os requisitos da LEP. Ademais, havendo recurso será expedida guia de recolhimento provisória, pelo que não haverá qualquer prejuízo, pois a progressão será apreciada pelo juízo competente. Além disso, sequer preenche o lapso temporal para tanto (preso em 10.03.22, pelo que ainda que considerado 2/5 só ocorreria em 12.05.25).

Por outro lado, “ad argumentandum”, ainda que se considere a detração conforme entendimento do STJ, o fato é que o regime não está atrelado apenas à pena, mas também às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, pelo que diante dos

múltiplos antecedentes e da reincidência (circunstância judicial agravante), não é recomendável outro regime diverso do acima fixado.

Quanto ao réu Rafael, levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, à razão mínima em face de sua situação econômica. Deixo de diminuir a pena pela confissão extrajudicial, porque já foi aplicada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Diminuo a pena de 1/2, considerando a quantidade média de drogas apreendidas (50 porções de maconha, 43 invólucros de cocaína e 59 pedras de "crack"), já que pequena quantidade nesta Comarca é inferior a 100 invólucros e enorme de quilos, posto que é primário, não ostenta antecedentes criminais e não ficou demonstrado que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa (art. 33, § 4.º).

Estabelecendo a lei a redução entre um sexto a dois terços o réu não tem direito à redução no máximo legal. Ademais, a quantidade de droga não foi considerada na pena-base, pelo que pode ser levada em conta para aplicar o redutor. Observo que o art. 42 da Lei n.º 11.343/06 se reporta ao art. 59 do Código Penal, o qual diz respeito à fixação da pena, ou seja, individualização da pena, o que abrange toda a pena e não apenas a pena-base, pelo que obviamente pode a quantidade de droga ser considerada no redutor. Inclusive inúmeros Acórdãos confirmaram sentenças deste juízo no mesmo sentido, pelo que pode se dizer que há jurisprudência.

O regime inicial de cumprimento da pena do réu Rafael será o aberto (art. 33, 2.º, "c" e § 3.º, do Código Penal e HC 111.840/ES do STF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14.06.2012 e HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. em 08.09.2020), porque o réu é primário, não ostenta antecedentes criminais e confessou na fase policial, demonstrando arrependimento, pelo que as circunstâncias judiciais são favoráveis e foi afastado pela jurisprudência do STF e do STJ o caráter hediondo do tráfico privilegiado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO JOILSON COSTA LAURIANO à pena de 2 (DOIS) ANOS, 8 (OITO) MESES e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME FECHADO, e 408 (QUATROCENTOS E OITO) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 37 da Lei n.º 11.343/06, e RAFAEL SILVA SOUZA à pena de 2 (DOIS) ANOS e 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME ABERTO e 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.

Incabível a substituição por pena restritiva de direitos ao acusado Joilson, uma vez que é reincidente em razão da prática de tráfico (fls. 63 - proc. 67770-98.2016). O "sursis" também é incabível ao réu Joilson, por ser reincidente em crime doloso (art. 77, inc. I, do Código Penal).

Tendo em vista que o réu Joilson foi preso em flagrante, bem como por estarem presentes os requisitos da preventiva, sendo crime de extrema gravidade, fazendo-se necessária a prisão para garantia da ordem pública para evitar a prática de novos crimes de gravidade e para assegurar a aplicação da lei penal, posto que nada há que o vincule ao distrito da culpa (não comprovou residência fixa nem ocupação lícita), conforme decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 92/97) e decisão de fls. 154, que a manteve nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP (reapreciação a cada 90 dias), e é incabível qualquer benefício, recomende-se na prisão em que se encontra.

Em relação ao réu Rafael, considerando a redação do art. 44, § 2.º, do Código Penal, bem como o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. em 08.09.2020, sendo a pena privativa de liberdade superior a um ano a substituo por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos consistente em proibição de frequentar determinados lugares, a serem fixados pelo juízo da execução, que são as mais adequadas para reprimir a sua conduta.

A pena restritiva de direitos terá a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída (art. 55 do Código Penal).

O acusado Rafael poderá recorrer em liberdade, porque é primário e após as substituições legais foram impostas apenas penas restritivas de direitos e multa. Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por serem beneficiários da Assistência Judiciária

(art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Considerando que o dinheiro apreendido (fls. 49 e 118), conforme prova produzida, é proveito do tráfico, determino o perdimento em favor da União, providenciando-se o necessário após o trânsito em julgado (art. 63 da Lei n.º 11343/06).

Transitada esta em julgado, lancem-se os nomes dos acusados no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 98), providencie-se o necessário quanto ao perdimento do dinheiro, comunicando-se ao SENAD (art. 63, § 4.º, da Lei n.º 11343/06) e efetuem-se os cálculos das multas, abrindo-se vista às partes.

Diadema, 27 de outubro de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA